Abolitio criminis mediata e traffico di influenze illecite

Traccia: *Premessi cenni sulla successione di leggi penali nel tempo, si soffermi il candidato sulle ipotesi di abolitio criminis "in via mediata", vale a dire attraverso l'abrogazione o la modifica di una norma diversa da quella incriminatrice, verificando, poi, la revocabilità ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), laddove la mediazione illecita fosse finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a commettere il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).*

Scaletta

1. **Introduzione.** La successione di leggi penali nel tempo: irretroattività della norma sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.) e retroattività della norma favorevole (art. 2 c.p.), con i relativi fondamenti (art. 3 Cost.; art. 7 CEDU). Distinzione tra abolitio criminis (art. 2, comma 2, c.p.), che travolge il giudicato, e successione modificativa (art. 2, comma 4, c.p.), che si arresta davanti alla sentenza irrevocabile.
2. **Il criterio distintivo.** Il confronto strutturale tra le fattispecie astratte e la continuità del tipo di illecito; l'abolitio parziale come area di fatti fuoriusciti dalla nuova incriminazione.
3. **L'abolitio in via mediata.** Le modifiche di norme diverse da quella incriminatrice: norme integratrici del precetto ed elementi normativi della fattispecie. Il criterio che distingue la modifica che incide sul disvalore del fatto da quella che muta solo la situazione di fatto o il contesto applicativo (il caso dei cittadini romeni e l'inosservanza dell'ordine di espulsione).
4. **L'art. 673 c.p.p.** La revoca della condanna come strumento esecutivo dell'art. 2, comma 2, c.p.; applicabilità all'abolitio parziale; poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione nei limiti del giudicato.
5. **Il caso.** Il traffico di influenze illecite dalla legge n. 190 del 2012 alla legge n. 3 del 2019; l'interpretazione restrittiva della «mediazione illecita» come mediazione finalizzata alla commissione di un reato; la legge n. 114 del 2024: abrogazione dell'abuso d'ufficio e riscrittura dell'art. 346-bis c.p., che ora richiede un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato.
6. **La soluzione.** Concorrono un'abolitio mediata (abrogazione dell'art. 323 c.p.) e un'abolitio diretta parziale (nuovo art. 346-bis c.p.). La mediazione finalizzata all'abuso d'ufficio esce dall'area penale e la condanna è revocabile ex art. 673 c.p.p., salvo che il fatto accertato integri un diverso reato-fine ancora previsto (ad esempio la corruzione propria).
7. **Conclusione.** Il ruolo del giudice dell'esecuzione e il valore di garanzia del principio di retroattività dell'abolitio, anche a fronte del giudicato.

Tema

Il principio di legalità, nella sua declinazione temporale, impone che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. L'art. 25, comma 2, Cost. eleva a rango costituzionale il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole, che l'art. 2, comma 1, c.p. già enunciava, in funzione di garanzia della libertà di autodeterminazione del cittadino, il quale deve poter conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie scelte. Diverso è il fondamento della regola opposta, quella della retroattività della norma favorevole, che non trova copertura nell'art. 25 Cost. ma nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.: sarebbe irragionevole continuare a punire, o a punire più severamente, un fatto che il legislatore ha ormai ritenuto non meritevole di pena, o meritevole di una pena più mite, solo perché commesso prima del mutamento normativo. Proprio perché fondata sull'art. 3 Cost., la retroattività favorevole è stata ritenuta dalla Corte costituzionale suscettibile di deroghe giustificate da interessi di rango analogo, come affermato in pronunce del 2006 e del 2011, nelle quali la Corte ha valorizzato anche l'art. 7 CEDU, letto dalla Corte di Strasburgo nel senso di garantire, oltre all'irretroattività della legge sfavorevole, anche l'applicazione della legge penale più mite sopravvenuta.

Sul piano codicistico l'art. 2 c.p. distingue nettamente due fenomeni. Il secondo comma disciplina l'abolitio criminis: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Il quarto comma regola invece la successione modificativa: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La differenza di disciplina è evidente, perché soltanto l'abolitio travolge il giudicato, mentre la successione modificativa si arresta di fronte alla sentenza irrevocabile; ed è altrettanto evidente la ragione, giacché quando il legislatore abolisce il reato viene meno lo stesso giudizio di disvalore che giustificava la pena, mentre quando si limita a modificare la disciplina quel giudizio permane, pur con una diversa intensità della risposta sanzionatoria. Sul versante processuale, l'art. 673 c.p.p. dà attuazione all'art. 2, comma 2, c.p., prevedendo che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti.

Decisivo diventa allora individuare il criterio per stabilire quando ricorra un'abolitio e quando, invece, una mera successione modificativa, specie nelle ipotesi in cui il legislatore abroghi una norma e contestualmente ne introduca un'altra. Alla tesi della continuità del tipo di illecito, che guarda al bene giuridico tutelato e alle modalità di aggressione, la giurisprudenza di legittimità ha preferito, con le Sezioni Unite del 2003 in materia di false comunicazioni

sociali, il criterio del confronto strutturale tra le fattispecie astratte. Se la nuova norma si pone in rapporto di specialità con la precedente, i fatti che rientrano in entrambe sono soggetti a successione modificativa, mentre quelli che, rientranti nella vecchia fattispecie, non sono riconducibili alla nuova sono oggetto di abolitio. Si delinea così la figura dell'abolitio parziale, che si realizza quando il legislatore, pur conservando l'incriminazione, ne restringe l'ambito applicativo, ad esempio aggiungendo un elemento specializzante, e fa così fuoriuscire dall'area del penalmente rilevante una porzione dei fatti in precedenza punibili.

Il problema si complica quando la modifica non riguarda la norma incriminatrice, ma una norma diversa, che con essa interferisce. È questo il terreno della cosiddetta abolitio criminis in via mediata, oggetto di un'ampia riflessione dottrinale [Gatta]. Molte fattispecie penali, infatti, non sono autosufficienti, ma rinviano a norme extrapenali o ad altre norme penali per la definizione del precetto o di singoli elementi del fatto tipico. Si pensi alle norme penali in bianco, il cui precetto è completato da fonti secondarie, o alle fattispecie che contengono elementi normativi, il cui significato dipende da una disciplina diversa, come la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.), l'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio o la stessa nozione di reato, quando questo compaia come elemento di un'altra fattispecie. Ci si chiede se la modifica della norma richiamata produca un fenomeno successorio rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p., e dunque, nel caso in cui restringa l'area del fatto punibile, un'abolitio idonea a travolgere anche il giudicato.

La risposta non può essere unitaria e dipende dalla funzione che la norma richiamata svolge rispetto alla fattispecie incriminatrice. Quando la norma richiamata integra il precetto, concorrendo a definire il contenuto di disvalore del fatto, la sua modifica in senso favorevole equivale a una modifica della norma penale stessa, e soggiace dunque all'art. 2 c.p. Quando invece la norma richiamata si limita a descrivere un presupposto di fatto o una qualità del soggetto o dell'oggetto, senza incidere sulla valutazione di disvalore espressa dalla norma incriminatrice, la sua modifica muta soltanto la situazione concreta cui la norma penale si applica, senza alcuna successione di leggi penali. Emblematica, in questo senso, la vicenda dei cittadini romeni, condannati per l'inosservanza dell'ordine di espulsione prima che la Romania entrasse nell'Unione europea. Le Sezioni Unite hanno escluso l'abolitio, osservando che l'acquisto della cittadinanza europea non aveva modificato la norma incriminatrice né il giudizio di disvalore sull'inosservanza dell'ordine, ma aveva semplicemente fatto venire meno, per il futuro, il presupposto di fatto della sua applicazione a quei soggetti. Il criterio che ne emerge impone dunque di chiedersi se la modifica della norma extrapenale o della diversa norma penale rifletta un mutamento della valutazione legislativa sul fatto incriminato o se, invece, si limiti a incidere sulla realtà cui quella valutazione si applica.

Questi principi consentono di affrontare la questione della revocabilità della condanna per traffico di influenze illecite, nel caso in cui la mediazione fosse finalizzata a indurre il

pubblico ufficiale a commettere un abuso d'ufficio. Il delitto di cui all'art. 346-bis c.p., introdotto dalla legge n. 190 del 2012 in attuazione degli obblighi internazionali in materia di lotta alla corruzione, punisce condotte prodromiche rispetto alla corruzione, anticipando la tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La legge n. 3 del 2019 ne ha ampliato la portata, abrogando il millantato credito (art. 346 c.p.) e attraendo nell'art. 346-bis c.p. anche le relazioni soltanto vantate, oltre a quelle esistenti. La formulazione della norma, tuttavia, faceva riferimento a una «mediazione illecita» senza definirla, ponendo un serio problema di determinatezza. La giurisprudenza di legittimità lo aveva risolto in via interpretativa, ritenendo illecita la mediazione finalizzata alla commissione di un fatto di reato da parte del pubblico agente, idoneo a produrre vantaggi al committente. Fra i reati-fine così rilevanti rientrava, appunto, l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

La legge n. 114 del 2024 ha inciso su questo quadro in una duplice direzione. Da un lato ha abrogato l'art. 323 c.p., espungendo l'abuso d'ufficio dall'ordinamento; la Corte costituzionale ha poi ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate in relazione a tale abrogazione, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Dall'altro lato ha riscritto l'art. 346-bis c.p., restringendone in più punti l'ambito applicativo: le relazioni con il pubblico agente devono essere esistenti e sfruttate intenzionalmente, l'utilità data o promessa deve essere economica e, soprattutto, la norma definisce ora la mediazione illecita come quella volta a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Il legislatore ha così recepito, precisandolo, l'orientamento interpretativo che individuava nel reato-fine il nucleo di disvalore della mediazione.

Nel caso proposto dalla traccia si intrecciano, dunque, due fenomeni. Vi è anzitutto un'abolitio in via mediata, perché l'abrogazione dell'art. 323 c.p., norma diversa da quella incriminatrice, fa venir meno il reato che qualificava come illecita la mediazione. Vi è poi un'abolitio diretta e parziale, perché il nuovo art. 346-bis c.p. richiede espressamente che l'atto contrario ai doveri d'ufficio costituisca reato, sicché le mediazioni finalizzate a un abuso d'ufficio, non più previsto come reato, non rientrano nella nuova fattispecie. Alla luce del criterio delineato in precedenza, la soluzione dell'abolitio appare obbligata. Il riferimento al reato-fine contenuto nell'art. 346-bis c.p. non descrive un mero presupposto di fatto, come nel caso della cittadinanza dello straniero espulso, ma esprime il contenuto stesso del disvalore della mediazione, che è punita in quanto strumentale alla commissione di un reato da parte del pubblico agente. Se il legislatore ha ritenuto che l'abuso d'ufficio non meriti più la sanzione penale, viene meno anche la ragione per punire la mediazione che a esso era finalizzata; e la nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p. lo conferma testualmente, poiché la mediazione rivolta a un atto non costituente reato è oggi estranea al tipo.

Ne discende che, rispetto ai fatti commessi prima della riforma, opera l'art. 2, comma 2, c.p. e non il quarto comma, con la conseguenza che il limite del giudicato non trova applicazione. La sentenza definitiva di condanna per traffico di influenze illecite, pronunciata in relazione a una mediazione finalizzata all'abuso d'ufficio, è pertanto revocabile ai sensi dell'art. 673 c.p.p. L'opinione prevalente riconosce infatti che la norma processuale si applica anche all'abolitio parziale, sebbene il suo testo faccia riferimento all'abrogazione della norma incriminatrice: il fondamento della revoca risiede nell'art. 2, comma 2, c.p., che non distingue tra abolitio totale e parziale, e sarebbe irragionevole consentire la prosecuzione dell'esecuzione per un fatto che, secondo la legge vigente, non costituisce più reato soltanto perché il legislatore ha scelto di restringere la fattispecie anziché abrogarla. Per i procedimenti ancora in corso, invece, la questione non si pone neppure in termini di revoca: il giudice della cognizione dovrà pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, verificando caso per caso se la mediazione fosse rivolta a un atto integrante un reato tuttora vigente. Si comprende così come la scelta tra abolitio e successione modificativa non abbia una valenza meramente teorica, ma determini la sorte stessa delle condanne definitive, che soltanto nel primo caso possono essere rimosse.

Resta da precisare quali siano i poteri del giudice dell'esecuzione. Questi non può procedere a una nuova valutazione del merito, ma deve verificare, sulla base della sentenza di condanna e degli atti del procedimento, se il fatto accertato rientri nell'area dei fatti oggetto di abolitio. Occorre dunque accertare quale fosse il reato-fine della mediazione, come ricostruito dal giudice della cognizione. Se la sentenza qualifica l'atto oggetto della mediazione come abuso d'ufficio, la revoca è dovuta. Se invece dal fatto accertato emerge che la mediazione mirava a un atto contrario ai doveri d'ufficio integrante un diverso reato ancora previsto dall'ordinamento, come la corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. o la turbata libertà degli incanti, il fatto continua a essere riconducibile al nuovo art. 346-bis c.p. e la revoca deve essere esclusa, operando al più la disciplina della successione modificativa nei limiti consentiti dal giudicato. Analogamente, il giudice dovrà verificare la sussistenza degli ulteriori elementi introdotti dalla riforma, come l'esistenza delle relazioni e la natura economica dell'utilità, poiché anche le condotte prive di tali requisiti, come quelle fondate su relazioni soltanto vantate, sono state espunte dalla fattispecie, salvo che il fatto accertato integri un diverso reato, quale la truffa.

La vicenda del traffico di influenze illecite mostra, in conclusione, come il fenomeno dell'abolitio criminis non possa essere colto guardando soltanto alla norma incriminatrice, ma richieda di considerare l'intero sistema di norme che concorrono a definire il fatto punibile. Quando la norma richiamata contribuisce a esprimere il disvalore del fatto, come accade per il reato-fine nel traffico di influenze, la sua abrogazione si riflette sull'incriminazione e produce un'abolitio, sia pure in via mediata, con tutte le conseguenze dell'art. 2, comma 2, c.p., ivi compresa la cedevolezza del giudicato. In questo senso l'art. 673 c.p.p. si conferma strumento

essenziale di attuazione del principio di uguaglianza in materia penale, perché impedisce che la pena continui a essere eseguita per un fatto che l'ordinamento non considera più reato, affidando al giudice dell'esecuzione il compito delicato di individuare, entro i confini del giudicato, i fatti che hanno perduto la propria rilevanza penale.